

死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品。其二，2013年和2021年《食安解释》亦规定，病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽、兽、水产动物肉类及其制品的，属于《中华人民共和国刑法》第一百四十三条“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”之情形。

第二，生产销售病死、死因不明的肉类及肉类制品的行为，具有刑法意义上的社会危害性。《中华人民共和国刑法》第一百四十三条及《食安解释》第一条对于生产、销售不符合安全标准的食品罪的罪状均表述为“足以造成……”“足以”二字表明刑法并未要求该罪名的成立以发生实害结果为构罪要件；由于食用病死、死因不明肉类及肉类制品对人体健康产生疾病种类、侵害程度难以穷尽预见和应对的风险，故该行为一经实施即形成危及人身的不合理危险，且属于刑法意义上的现实紧迫的高度危险。本案中，涉案病死、死因不明鳊鱼所制烤鳊成品销售持续时间长达七年之久，销售范围面向我国多个省份，现实危险的紧迫程度不在于食品安全事故的发生概率之大，乃在于该危险一旦发生即导致食品安全事故或食源性疾病波及地域范围广、受损人数多、危害程度深、挽损成本大，相关生产销售行为当以犯罪论处。

第三，“检验检疫合格”不属于法律逻辑层面的出罪情形，在科学技术层面亦无法否定经营病死、死因不明肉类及其制品行为的社会危害性。一方面，“病死、死因不明”与“检验检疫不合格”同属《食安解释》第一条第二项规定“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”的情形，二者系“或”字连接的并列逻辑关系。立法入罪的逻辑形式为“A 或 B”，作为出罪的否命题形式则为“非A 且非B”，即行为人同时满足“不属于病死、死因不明”且“检验检疫合格”两种情形，方可出罪。换言之，行为人经营病死、死因不明肉类及其制品的行为一经查证属实，无论检验检疫是否合格，均成立本罪。另一方面，受限于科技发展水平、当前医疗认知、检验检疫范围与参照标准，涉案烤鳊成品在狭义的技术层面“检测合格”仅为相对而言，无法绝对排除食用病死、死因不明可能导致的潜在危害，此乃法律及刑事司法解释历经多次更迭完善，但始终保留禁止经营病死、死因不明肉类及制品条款的根本原因。退

一步而言，倘若“检验检疫合格”能够成为经营病死、死因不明肉类及其制品出罪的背书，那么不仅架空了《中华人民共和国食品安全法》和《食安解释》的禁止性规定，更冲击了普罗大众最朴素的正义情感，有悖于常情常理。

二、行为人成立生产、销售不符合安全标准的食品罪，一般同时成立生产、销售伪劣产品罪并择一重罪处罚

第一种观点认为，涉案病死、死因不明的鳊鱼属于食品原料，没有经过加工、制作和销售，不属于“产品”，且不存在《中华人民共和国产品质量法》所规定的危及人身、财产安全的不合理危险等伪劣产品范畴，故涉案死鳊及制品不属于《中华人民共和国刑法》第一百四十条的罪名评判范畴，各行为人不成立生产、销售伪劣产品罪。第二种观点认为，各行为人生产销售的病死、死因不明的鳊鱼烤制成品，既属于《中华人民共和国刑法》第一百四十三条规定不符合安全标准的食品，涉案食品面向市场不特定多数人进行销售，故又属于《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定的伪劣产品；行为人同时触犯两个罪名，应根据《中华人民共和国刑法》第一百四十九条第二款的规定择一重罪论处；其中，为生产销售环节提供病死、死因不明鳊鱼原料的行为人，以共同犯罪论处。生效裁判支持第二种意见，具体理由如下。

第一，《中华人民共和国刑法》对于生产、销售伪劣产品罪与生产、销售不符合安全标准的食品罪的保护法益存在交叉。本案中，行为人生产销售病死、死因不明鳊鱼及烤鳊制品的行为，同时侵害了市场竞争秩序和消费者人身权益。不符合安全标准的烤鳊成品（食品）面向全国范围内的不特定多数人销售，具有商品流通的属性；本案中，多数被收购倒卖的病死、死因不明鳊鱼行为扰乱了正常的水产肉类加工销售的经济秩序，尤以福清本地的鳊鱼产业为甚。以病死、死因不明鳊鱼为食材的烤鳊成品销售，销售范围难以追溯，对人体健康产生的疾病难以预见，具有足以产生严重食物中毒事故或其他食源性疾病的危害，严重侵害消费者的生命健康权。

第二，生产、销售伪劣产品罪与生产、销售不符合安全标准的食品罪形成竞合。在理论层面，对于本节罪名之间系想象竞合还是法条竞合关系，理论界

尚未达成共识。^①但在规范层面，无论形成何种竞合，择一重罪处断已有定论。^②具言之，两个罪名分属《中华人民共和国刑法》第三章第一节“生产、销售伪劣商品罪”罪名体系下犯罪对象，前者“伪劣产品”系一般性的伪劣商品，而后者“不符合安全标准的食品”与有毒有害食品、假药、劣药、不符合标准的医用器材、不符合卫生标准的化妆品等对象并列，共属特定的伪劣商品。故不符合安全标准的食品当然属于伪劣产品。对此，《中华人民共和国刑法》第一百四十九条第二款及《食安解释》第十三条第一款均作出“依照处罚较重的规定定罪处罚”的提示性规定。

第三，择一重罪处罚能够实现罪责刑相适应的刑法基本原则。鉴于本案尚无证据证实已经造成《食安解释》第四条规定的致人死亡、重度残疾、30人以上食物中毒等特别严重后果，全案仅按照生产、销售不符合安全标准的食品罪定罪处罚，无法在七年以上有期徒刑处刑，在生产销售伪劣商品的罪名体系内部横向比较，明显罚不当罪；全案21名行为人在7年以下量刑，亦无法根据各被告人的地位作用有效拉开量刑梯度，导致量刑失衡。本案根据各行为人的犯罪金额，灵活适用两个罪名依法择一重罪处罚，既能够有力震慑犯罪分子，彰显司法机关捍卫食品安全的决心，也能够拓宽全案在有期徒刑十五年以下量刑的空间，平衡全案量刑并对其中主犯予以重点打击，进而最终实现罪责刑相适应。

综上所述，本案21名被告人购销病死、死因不明的鳊鱼并予以加工销售的行为，同时触犯生产、销售伪劣产品罪和生产、销售不符合安全标准的食品罪；本案对于销售金额在200万元以上的郑某1、郑某2等19名被告人，以处罚较重的生产、销售伪劣产品罪论处；对郑某1(21万余元)、吴某富

^①如张明楷：《论“依照处罚较重的规定定罪处罚”》，载《法律科学》2022年第2期，认为《中华人民共和国刑法》第一百四十九条第二款规定的是想象竞合；对此，王彦强：《〈刑法修正案(十一)〉中竞

~812页等。

合条款的理解与适用》，载《政治与法律》2021年第4期，认为 是交叉关系的法条竞合。

②胡云腾、熊选国、高憬宏、万春主编：《刑法罪名精释(上)》，人民法院出版社 2022年版，第191～192页；陈兴良主编：《刑法各论精释》，人民法院出版社2015版，第811

~812页等。

(6万余元)以处罚较重的生产、销售不符合安全标准的食品罪定罪处罚，符合法律规定。

编写人：福建省福州市中级人民法院
吴刚 福建省福州市人民检察院
阮露玫

生产、销售地沟油案件中“有毒有害食品”的认定①

—— 沈某等生产、销售有毒、有害食品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2022)渝03刑终35号刑事裁定书

2. 案由：生产、销售有毒、有害食品罪

【基本案情】

被告人沈某和被告人李某某系夫妻关系，2012年7月至2019年11月，二人先在其家中开设私人作坊，后于2016年7月15日，由沈某个人出资注册成立沈某炼油厂，从事“地沟油”的炼制及销售。在生产“地沟油”的过程中，沈某从各屠宰场收购含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等猪肉废弃物，先后雇佣被告人沈某甲、刘某甲等人将上

述猪肉废弃物炼制成“食用猪油”并销售给被告人罗某某、刘某、王某某、庞某某等人。沈某负责收购上述猪肉废弃物，组织工人生产及销售；李某某负责协助炼制和销售。沈某和李某某二人生产、销售“食用猪油”金额共计107万余元。罗某某、刘

①入库案例，参见人民法院案例库2023-02-1-072-010。

某、王某某、庞某某在明知沈某生产的“食用猪油”是由猪肉废弃物等非食品原料加工而成，仍多次向沈某购买，并将购进的食用猪油销售至多地用于食品加工以及餐馆用油。2019年11月13日，沈某、李某某、沈某甲、刘某甲于生产窝点被当场抓获，公安机关现场扣押“食用猪油”1838.3公斤，猪肉废弃物1480.7公斤，以及炼油所用的活性白土等。同日，罗某某、刘某、王某某、庞某某亦被公安机关分别抓获。

【案件焦点】

含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等猪肉废弃物是否属于有毒、有害的非食品原料。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：被告人沈某、李某某、沈某甲、刘某甲在生产、销售的食物中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪，且系共同犯罪；被告人罗某某、刘某甲、王某某、庞某某销售明知掺入有毒、有害的非食品原料的食物，其行为均已构成销售有毒、有害食品罪。据此，对本案8名被告人分别判处十一年至一年三个月不等有期徒刑，并处10万元至155万元不等罚金。追缴各被告人犯罪所得，上缴国库。对没收扣押在案的“食用猪油”及生产原料由扣押机关依法处理。责令各被告人在省级以上媒体对其犯罪行为公开赔礼道歉。

沈某、罗某某、刘某甲、王某某不服，提出上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于：（1）含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等猪肉废弃物是否属于有毒、有害的非食品原料；（2）对“地沟油”

的检测报告是否是司法机关认定“有毒、有害食品”的前提。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法严惩“地沟油”犯罪活动的通知》(以下简称《地沟油通知》)的精神,“地沟油”犯罪,是指用餐厨垃圾、废弃油脂、各类肉及肉制品加工废弃物等非食品原料,生产、加工“食用油”,以及明知是利用“地沟油”生产、加工的油脂而作为食用油销售的行为。其中,“地沟油”来自社会公众的通俗称谓。

本案的特殊之处在于,沈某等人生产、加工“食用油”的原料系含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等猪肉废弃物,并非普通民众认知的传统“地沟油”原料,如餐厨垃圾、废弃油脂,对该部分炼制原料能否认定为有毒、有害的非食品原料。

一、利用含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等猪肉废弃物炼制的“食用油”,应当视为“地沟油”

有观点认为,现有法律规范,法律法规均未对“肉制品加工废弃物”进行定义,也没有对其范畴进行明确界定,将含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等认定为猪肉加工废弃物,从而作为“地沟油”犯罪处理无法律依据,有违罪刑法定原则。

“废弃物”不是法律概念,其范畴亦不需要法律明确界定,凭日常生活常识分辨即可。含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等物相对于食品公司来说,已不具备应有的食用价值,属肉制品加工废弃物无疑,不能因被告人刘某等人可用其来炼制劣质猪油而否认其肉制品加工废弃物的性质。刘某等人利用猪肉加工废弃物生产、加工“食用油”,根据《地沟油通知》的规定,应当作为“地沟油”犯罪追究其刑事责任。

二、对“地沟油”的检测报告不应是司法机关认定“有毒、有害食品”的唯一依据

有观点认为,被告人刘某等人炼制“食用油”的原料虽然有问题,但检测报告显示“食用油”的各项理化指标均合格,没有检出有毒、有害成分,达到了食用标准,不宜认定为有毒、有害食品。

